

1500590-21.2021.8.26.0630
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR
Comarca: Americana
Foro: Foro de Americana
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 07/12/2022
... 29 de janeiro de 2020)

APELAÇÃO - Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa - Preliminar - Nulidade da sentença - Ausência de enfrentamento das alegações defensivas e falsidade dos depoimentos judiciais dos policiais militares - Inocorrência - Decisão motivada - Desnecessidade de menção pormenorizada sobre cada um dos argumentos apresentados - Pequenas divergências nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Americana
Foro de Americana
2ª Vara Criminal
Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500590-21.2021.8.26.0630 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500590-21.2021.8.26.0630
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2193194/2021 - 03º D.P. AMERICANA, 19093994 - 03º D.P. AMERICANA, 954/21/346 - 03º D.P. AMERICANA, 2193194 - 03º D.P. AMERICANA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ABNER DE SOUZA BALDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

ABNER DE SOUZA BALDO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos II e IV, c.c. o artigo 70, ambos do Código Penal, porque, na data e local descritos na denúncia, no período noturno, previamente ajustado e com unidade de desígnios com JULIANA LUIZ LIMA DA CRUZ MARINHO, mediante escalada, subtraíram, para o proveito comum, 50 metros de cabos elétricos, avaliados em R\$1.400,00, pertencentes a F.L.F. e A.F.

A denúncia foi recebida em 04 de outubro de 2021 (fls. 172/173).
O réu foi citado pessoalmente (fls. 217), apresentando defesa (fls. 254).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas. O réu deixou de comparecer ao interrogatório, tornando-se revel (fls. 299).

O Doutor Promotor de Justiça (fls. 303/307), entendendo estarem suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu pelo delito de furto qualificado tentado, no entanto, na forma tentada.

O Doutor Defensor do réu (fls. 310/312) requereu a absolvição ante a ausência de provas.

Ante a alegação de matéria preliminar, os autos retornaram ao Ministério Público para manifestação (fls. 321/322).

Os autos foram desmembrados em relação à acusada Juliana (fls. 313).

É, em síntese, o relatório.
DECIDO.

A preliminar de inépcia da denúncia, não deve ser reconhecida, tendo em vista que a prefacial atende os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em inépcia. Segundo o entendimento da jurisprudência:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. REJEITADA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE COM DIVERSAS PASSAGENS CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. PERICULOSIDADE SOCIAL. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2.

Rejeitada a preliminar de inépcia da denúncia. Ao contrário do alegado, foram atendidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, tendo sido exposto o fato criminoso e suas circunstâncias, com a devida qualificação do recorrente e demais acusados, classificação do crime e indicação do rol de testemunhas. A tese de insuficiência das provas de autoria ou participação resume-se à alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 3.

(...). 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 533.767/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 21/10/2019)

DENÚNCIA - Requisitos do art. 41 do CPP - Prolixidade e luxo de pormenores - Desnecessidade: 62 - A exigência do Código de Processo penal, em seu art. 41, quando a exposição do fato criminoso com "todas as suas circunstâncias", não significa que a denúncia deva ser prolixa, contendo pormenores existentes nas peças do inquérito. RJDACRIM VOLUME 23 JULHO/SETEMBRO/1994 PÁGINA: 134 RELATOR: - SILVA RICO.

DENÚNCIA - Atendimento aos pressupostos da Lei Processual Penal - Inépcia - Inocorrência: 216(a) - A denúncia onde se acha presente fato normal, atribuído a culpados, cumpre os reclamos da Lei Processual Penal, não podendo ser taxada de inepta. RJDACRIM VOLUME 24 OUTUBRO/DEZEMBRO/1994 PÁGINA: 416 RELATOR: - SILVEIRA LIMA

DENÚNCIA - Ausência de descrição pormenorizada da participação de cada co-réu -

Nulidade - Inocorrência:279 - Inocorre nulidade da peça inicial, pelo fato do Promotor não descrever pormenorizadamente a participação de cada co-réu no evento criminoso, máxime quando tal atitude, em nenhum momento, impediu o réu de exercer sua defesa. RJDTACRIM VOLUME 23 JULHO/SETEMBRO/1994 PÁGINA: 486 RELATOR: - CANELLAS DE GODOY.

No mais, trata-se de delito de furto, o qual é devidamente tipificado, e não de norma penal em branco e que necessita de complementação.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos autos de fls. 01/02, 13/16 e 17/24, e laudo de fls. 126/135.

A autoria é indubitosa.

Os réus foram presos em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra Do Flagrante Delito, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

"Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloqüente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Na ocasião, os réus estavam na posse do bem subtraído. A apreensão do bem subtraído em poder do acusado implica em forte prova indiciária, nos termos da melhor doutrina (cf. FRANÇOIS GORPHE, "De la Apreciación de las Pruebas", tradução de Alcalá Zamora y Castillo, 1ª Ed., EJEA, Buenos Aires, 1950, pág. 316; ERICH DÖRING, "La Prueba, su Practica y Apreciación", tradução de Tomás Banzhaf, 1ª ed., EJEA, Buenos Aires, 1986, pp. 367-8; CAMARGO ARANHA, "Da Prova no Processo Penal", 3ª Ed., Saraiva, 1994, cap. XVI, ns. 2 e 8, págs. 166 e 175).

Nesse caso, cabe à Defesa o ônus de provar a origem lícita do bem. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) 2. Ademais, 'em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa

inequívoca', o que não ocorreu na espécie, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade de sua versão. 3. (...)." (STJ - ARE 329.535/PI Rel. Min. Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE - 6ªT. DJE 25.08.2014)

ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - depoimento de vítima indicando como autor - validade - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. (...) (TJSP - APL: 00087038720118260533 SP 0008703-87.2011.8.26.0533, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 04/12/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/12/2014)

"(...) é cediço que, em se tratando de delito patrimonial, a apreensão da "res" em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca para o fato, sob pena dessa presunção se transmutar em certeza apta a ensejar o decreto condenatório (...)" (TJSP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº. 0078089-91.2010.8.26.0000, Rel. Des. Amado de Faria, j. 26.05.11);

A vítima F.L.F., ouvida em Juízo, informou que trabalhou até cerca de uma hora da manhã, fechando o quiosque. Disse que por volta de três horas da manhã foi comunicado pelos policiais acerca da subtração e apreensão de suspeitos. Dirigiu-se ao local, onde constatou a subtração da fiação de energia do estabelecimento, tendo prejuízo aproximado de R\$ 150,00.

E, a vítima A.F., ouvida em Juízo, informou que durante a madrugada foi comunicado pelo vizinho de quiosque acerca do furto. Disse que dirigiu-se ao local, onde já se encontravam os policiais com pessoas apreendidas. Narrou que verificou a ausência dos cabos de energia que ligam do poste para o quiosque. Por fim, teve um prejuízo aproximado de R\$ 450,00.

Não há nos autos prova de que as vítimas conheciam os réus anteriormente ou que tivessem intenção de prejudicá-los, atribuindo-lhes falsamente a prática de crime.

É fundamental o depoimento da vítima/testemunha como prova para a condenação. De acordo com a doutrina:

"...Um exame a respeito da interpretação jurisprudencial sobre a validade e credibilidade do depoimento do ofendido nos leva a duas vertentes, cada qual com sua fonte própria: a pessoa da vítima e a natureza do crime.

O primeiro elemento a ser examinado diz respeito à pessoa do ofendido: os antecedentes e a formação moral (RT, 154:50 e 219:92, e RF, 218:371); a idade (RT, 195:355); o estado mental e a maneira firme ou titubeante como presta seu depoimento (RT, 269:136).

A soma dos resultados obtidos com a análise de cada um de tais fatores levará a uma maior ou menor credibilidade.

Em segundo lugar, há que se examinar diante da natureza da infração. Certos delitos são cometidos na clandestinidade, às ocultas, de sorte a, na maior parte das vezes, contar somente com a força acusatória da palavra do ofendido.

Entre eles podemos citar os delitos contra os costumes e o roubo, pela própria essência perpetrados às ocultas.

Em tais casos admite-se a palavra da vítima como alicerce condenatório, desde que segura, crível e verossímil.

(...)

'Considerando-se que o assalto dificilmente conta com testemunhas, a palavra da vítima assume importância, principalmente quando se mostra segura e coerente'

(JTACrim 51:423).

'No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecido, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes' (RT, 484:320). No mesmo sentido: JTACrim, 60:314, 64:193, 73:79 e 22:354.(CAMARGO ARANHA, Adalberto José Q. T. de, Da prova no Processo Penal. 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006, pp. 150/151).

Sobre a importância do depoimento da vítima e testemunhas em casos de delitos contra o patrimônio, já decidiu a jurisprudência:

"(...) MÉRITO ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA Inocorrência. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância à palavra das vítimas como elemento de prova, desde que não destoem do conjunto probatório e que não se encontrem, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes. Impossível a absolvição quando as provas não deixam dúvidas quanto à autoria. (...)". (TJSP, Apl. Crim.0002294-84.2017.8.26.0210, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 05.02.2020).

ROUBO - Palavra da Vítima - Valor Probante - "Nos delitos patrimoniais, pelo geral cometidos na clandestinidade, apenas com a presença dos sujeitos ativo e passivo, é a palavra da vítima relevante para o reconhecimento do autor e serve de base para sua condenação"(TACRIM - Ap. nº 1.023.8013 - Limeira - 7ª Cam. - Rel. Juiz JOSÉ HABICE - j. 5.9.96, v.u.)

Os guardas municipais esclareceram que estavam em patrulhamento e foram informados de um possível furto em andamento, visualizado por câmeras de monitoramento, com um indivíduo nos postes fazendo a subtração de fios, e uma moça na rua, realizando a vigilância. Dirigiram-se até o local, onde depararam-se com as partes feminina e masculina, sendo que este já estava ao solo. Efetuada a abordagem, em revista pessoal não encontraram nada de ilícito, mas do lado do poste encontraram uma mochila contendo cabos de energia, além de ferramentas. Indagados, os réus negaram o delito. Informaram que os quiosques ficam na praça, bem próximos do local da abordagem. Por fim, as vítimas compareceram ao local e reconheceram os objetos subtraídos.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

"Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eundem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas" (Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça - art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) - Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente - (...). (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São

Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

APELAÇÃO - Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa - Preliminar - Nulidade da sentença - Ausência de enfrentamento das alegações defensivas e falsidade dos depoimentos judiciais dos policiais militares - Inocorrência - Decisão motivada - Desnecessidade de menção pormenorizada sobre cada um dos argumentos apresentados - Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não são suficientes para macular a prova colhida - Policiais que não teriam qualquer motivo para incriminar falsamente os acusados - (...) - Sentença mantida - Recurso não provido (Apelação nº 1501078-10.2017.8.26.0567, da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: SALLES ABREU, Data: 011 de agosto de 2018)

Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. 63 (b) - As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato. RJDTACRIM VOLUME 6 PÁG.78 ABRIL/JUNHO/90 RELATOR:-JOSÉ HABICE.

Não procedem, ainda, as alegações da defesa quanto à divergência dos depoimentos dos policiais. O depoimento dessas testemunhas tem o mesmo valor que o de qualquer outra, ainda mais quando a mera alegação de sua imprestabilidade vem desacompanhada do menor indício de prova, como no caso dos autos. O entendimento jurisprudencial não é diverso:

APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. (...). 4. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10).(...). (TJSP; Apelação Criminal 3004956-73.2013.8.26.0318; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/11/2017; Data de Registro: 17/11/2017)

O réu nem sequer se dignou em comparecer em Juízo para dar sua versão dos fatos.

Os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra os acusados, inclusive acerca das qualificadoras, tendo em vista a comprovação do concurso pelas declarações iniciais, reforçada pelas testemunhas.

Ainda, a qualificadora de escalada encontra-se demonstrada pela prova testemunhal, de acordo com o artigo 167 do Código de Processo Penal, bem como pelo laudo de fls. 126/135, não havendo falar-se em qualquer afastamento de qualificadora.

Assim, em que pese a defesa apresentada, não é possível o reconhecimento da exclusão das qualificadoras ou desclassificação do delito.

Referente a qualificadora do repouso noturno, resta caracterizada, tendo em vista ter o agente utilizado de período de menor vigilância da vítima.

1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. (TEMA 1144, STJ - Recursos Especiais n. 1.979.989/RS en. 1.979.998/RS)

No entanto, há que se analisar a recente Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça - Tema 1087 (Recursos Representativos - REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ), delimitando que: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Narra, ainda, o referido acórdão (REsp 1888756/SP):

"Assim, é razoável admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena. Em outras palavras, se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP). Nessa oportunidade, o órgão julgador avaliará, sob a ótica de sua discricionariedade, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, podendo, se assim considerar, analisar a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime com maior reprovabilidade. Esse proceder possibilitaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto".

Assim, mesmo que a referida causa de aumento não possa ser individualmente aplicada, no presente caso, tendo em vista a ocorrência da qualificação no delito de furto, resta passível sua análise na primeira fase, como circunstância judicial.

Além desses indícios, existe outro forte indício, que é a existência de processo por crime contra o patrimônio já sentenciado (fls. 57/58), o que, embora por si só não possa ser considerado como prova, fortalece a convicção judicial. Já decidiram nossos tribunais:

PENAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DUAS ESPÉCIES DE ENTORPECENTES. INDICATIVOS DE PRÁTICA CONTINUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...). 2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o fato que ensejou o flagrante não constituiu evento isolado na rotina do recorrente, quer em razão da diversidade e da quantidade de drogas apreendidas (11g de cocaína, fracionada em 19 porções e 29g de maconha, fracionada em dois invólucros), quer em razão de ele ser reincidente específico, circunstâncias essas que formam indicativo de prática de traficância de forma continuada, a evidenciar a sua periculosidade

social, o que é suficiente para justificar a segregação para o fim de garantir a ordem pública, prevenindo-se, assim, a provável reiteração delitiva. 3. Recurso ordinário desprovido. (RHC 64.919/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)

ANTECEDENTES CRIMINAIS - Utilização como prova - Impossibilidade:14(b) - Os antecedentes do acusado não constituem prova; contudo, inequívoca e capitalmente, reforçam convicção, quando evidenciam que o ato incriminado nada mais é do que rotina em seu proceder. (Apelação nº 1.035.97/8, Julgado em 03/02/1.997, 12ª Câmara, Relator: - Junqueira Sangirardi, RJTACRIM 34/69)

ANTECEDENTES - Influência na fixação do escarmento - Ocorrência: 12(a) - Os antecedentes não constituem prova suficiente à expiação, mas fortalecem o convencimento judicial e influem na fixação do escarmento, por expressa previsão legal. RJDTACRIM VOLUME 28 OUTUBRO/DEZEMBRO/1995 PÁGINA: 39 RELATOR: - RENATO NALINI.

PROVA - Maus antecedentes - Valor: 30(d) - Os antecedentes negativos não servem de base exclusiva para decreto condenatório mas constituem importante adinículo para a formação do convencimento. (Apelação nº 1.171.909/6, Julgado em 03/02/2.000, 7ª Câmara, Relator: Corrêa de Moraes, RJTACRIM 47/133)

A respeito da prova indiciária, nesse sentido é o entendimento da doutrina: "A prova da autoria não se faz apenas por confissão espontânea ou por declaração das testemunhas, mas, muitas vezes, com base em prova meramente indiciária. Constitui erro crasso, como diz Mestre Frederico Marques, citando Vito Gianturco, o afirmar-se de que nenhuma presunção, por mais veemente que seja, dará lugar à condenação, pois tal assertiva equivaleria a abolir-se a prova indiciária do processo penal (MARTINS, Weber "O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal - Forense - Rio de Janeiro - 1995 - p. 459).

Como já entendido por nossos Tribunais:

APELAÇÃO - RECEPÇÃO DOLOSA PROVA INDICIÁRIA E CIRCUNSTANCIAL - CONDENAÇÃO VALIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade: Existindo provas indiciária e circunstancial concludentes, no que tange a existência da consciência da origem espúria do bem pelo agente, circunstâncias essas aliadas à palavra dos policiais que não teriam motivo algum para uma falsa inculpação, impossível de se cogitar a absolvição. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000710-58.2011.8.26.0091; Relator (a): J. Martins; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; ANTIGO Foro Distrital de Brás Cubas - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/08/2014; Data de Registro: 09/09/2014)

"O indício vale como qualquer outra prova e impossível o estabelecimento de regras práticas para apreciação do quadro indiciário. Em cada caso concreto, incumbe ao juiz sopesar a valia desse contexto e admiti-lo como prova, à luz do artigo 239 do Código de Processo Penal" (Ap.1070845/5, Rel. Renato Nalini, j. 06.10.1997, rolo 1132, flash 0194, fls.09).

PROVA - Presença de indícios concatenados - Ausência de prova direta que os desautorize - Validade - Entendimento:61 - Sendo a prova indireta mas segura, formada por indícios concatenados, sem contra-indícios ou prova direta que os desautorize, possível é a condenação nela baseada, mormente se a materialidade do delito é inconteste. RJDTACRIM VOLUME 16 OUTUBRO/DEZEMBRO/1992 PÁGINA: 133 RELATOR: - MARREY NETO

PROVA - Furto - Presença de indícios - Valor:182 - Sendo os crimes de furto praticados normalmente sem a presença de testemunhas, os indícios passam a ter valor relevante para a apuração da autoria. RJDTACRIM VOLUME 25 JANEIRO/MARÇO/1995 PÁGINA: 324 RELATOR: - MESQUITA DE PAULA

Ainda, mediante uma só ação, os réus ofenderam direitos patrimoniais distintos, nos termos do disposto no artigo 70 do Código Penal.

HABEAS CORPUS. ROUBO. ART. 157, § 2.º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. DELITOS PRATICADOS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, CONTRA DIVERSAS VÍTIMAS. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO OBJETIVO, VINCULADO AO NÚMERO DE VÍTIMAS. SENTENCIADO EM CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO PROCESSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA A DETERMINAÇÃO DO NOVO REGIME PRISIONAL. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Na espécie, o crime de roubo foi cometido no interior de um coletivo, contra 05 (cinco) vítimas, mediante ameaça de morte feita com arma de fogo municada e apta para produzir disparos. 2. Resta caracterizado o concurso formal quando praticado o crime de roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos. Precedentes. 3. O Tribunal de origem, na terceira fase de aplicação da pena, aumentou as penas do Paciente acima do patamar máximo estabelecido no art. 70 do Código Penal. 4. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que "[o] percentual de aumento decorrente do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) deve ser aferido em razão do número de delitos praticados, e não à luz do art. 59 do CP [...]" (HC 136.568/DF, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 13/10/2009). 5. A determinação do regime prisional, na hipótese, tendo em vista que o Paciente cumpre pena por outras condenações, compete ao Juízo da Execução Penal, em razão do que preceitua o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal. 6. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida, para redimensionar as penas do Paciente, fixando-as em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezesete) dias-multa, mantida, no mais, a condenação. (HC 173.068/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 16/10/2013)

Por fim, conforme se verifica pelos depoimentos prestados, o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos réus, qual seja, o de terem sido surpreendidos pelos policiais, ainda muito próximos do local da subtração.

Diante da robustez do conjunto probatório, a condenação do acusado pela prática de furto é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Nos termos do art. 59, do Código Penal, tratando-se de furto duplamente qualificado (escalda e concurso) e, ainda, levando-se em conta a sua ocorrência durante o repouso noturno, o qual é valorado como circunstância judicial negativa neste caso, há maior reprovabilidade da conduta do acusado, justificando a fixação da pena base acima do mínimo legal. Exaspero, por isso, a pena base em 1/4 (um quarto), delimitando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não se verificam circunstâncias agravantes ou atenuantes a analisar.

Ante a ocorrência de concurso formal (art. 70, do CP), em relação aos dois crimes de furto, aplico ao réu a pena de um dos crimes, porque idênticas, aumentada em 1/6 (um sexto), observando a quantidade de vítimas e patrimônios atingidos, e fixo a pena base em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Tendo em vista que o delito se deu na forma tentada, diminuo a pena de 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido, que se aproximou sobremaneira da consumação, porquanto chegou a destruir o obstáculo para a subtração, perfazendo assim um total de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 09

(nove) dias-multa.

À míngua de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto.

Por ser primário, o réu poderá apelar em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal condenar o réu ABNER DE SOUZA BALDO às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto, e 09 (nove) dias-multa, no piso, como incurso no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, c.c. artigo 14, inc. II, e 70, "caput", todos do Código Penal.

Nos termos dos artigos 43 e seguintes, do Código Penal, em especial os incisos I e IV, do art. 43, converto a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, na forma de prestação de serviços à comunidade, por igual período ao da pena privativa de liberdade, a ser definida pelo Juízo das Execuções, e em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, em favor de entidade filantrópica do Município.

Por fim, considerando ser o réu assistido pela defensoria pública, presumindo-se a insuficiência de recursos, isento-o das custas.

P. I. C.

Americana, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA